

1500578-98.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, no caso presente, o acusado guardava em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente "maconha", tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

3ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena - SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500578-98.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500578-98.2022.8.26.0168

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Roberto Vieira da Silva

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu WAGNER ROBERTO VIEIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 18h00, na Rua Ceará, nº 433, Bairro Industrial, na cidade de Ouro Verde, nesta Comarca de Dracena/SP, mantinha em depósito e guardava droga (maconha), para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva no dia 07/04/2022 (fls. 84/94).

Regularmente notificado (fls. 185), o réu apresentou defesa prévia (fls. 66/77).

A denúncia foi recebida em 06/05/2022, ocasião em que foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento virtual por meio de videoconferência (fls. 141/144).

Durante a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu (cf. mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalte-se que não há se falar em desrespeito ao sigilo dos dados existentes no aparelho celular do acusado, porque houve autorização judicial para a realização da perícia técnica no celular apreendido, conforme r. decisão de fls. 125/126, e, conforme os depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo, eles não tiveram acesso ao conteúdo do celular do réu.

Outrossim, mostra-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na diligência policial, desencadeada por denúncia de tráfico, tampouco ausência de ato essencial, pois elaborado o laudo pericial de constatação provisória da substância entorpecente a fls. 22/27 e 28/33 e laudos de exame químico toxicológico definitivos (fls. 163/165 e 166/168).

Ademais, o art. 5º, XI, da Constituição da República permite que se entre na residência sem mandado quando houver flagrante delito (neste caso, a traficância), não havendo constrangimento ilegal neste particular:

“Art. 5º. (...)

XI. a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Assim, não há que se falar em nulidade na busca e apreensão realizada na casa do réu, pois demonstrada a situação de flagrância, haja vista que o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a terceiro. E, havendo flagrante delito, existe permissivo constitucional para a invasão domiciliar desprovida de autorização judicial.

Nesse sentido:

“A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções, não protegendo o indivíduo em atividade criminosa no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente, a ausência da autoridade ou a falta do respectivo mandado, não maculam a busca e apreensão, inocorrendo, igualmente, nulidade da prisão em flagrante” (TJSP Habeas Corpus nº 68.215-3 Rel. Diwaldo Sampaio RJTJSP 115/257).

Desse modo, o ingresso dos policiais na residência do réu, sem prévia autorização judicial para efetuar a apreensão da droga, não tem o condão de tornar ilícita a prova. É que se tratando de crime permanente, desnecessário se faz a expedição de mandado de busca.

Portanto, considera-se válida a apreensão da droga, inexistindo ilegalidade na diligência policial, desencadeada por denúncia de tráfico. Tratando-se “de crime permanente, a ensejar sempre prisão em flagrante, não há que se questionar sobre a preexistência, nulidade ou descumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, porque a inviolabilidade domiciliar é princípio que não se compadece, em termos infracionais, com o desvio de finalidade da função da própria casa, conforme se infere do disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal” (JCAT 75/590).

No mesmo sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e Corrupção. Nulidade. Prova ilícita. Busca e apreensão sem mandado judicial. Inocorrência. Busca domiciliar autorizada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República. Tráfico de entorpecentes é crime permanente. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente caracterizadas. Pena corretamente aplicada e fundamentada. Regime de cumprimento de pena alterado do integral para o inicial fechado, em razão da superveniência da Lei nº 11.464/2007 (que deu nova redação ao artigo 2º e §§, da Lei n. 8.072/90).

Preliminar rejeitada. Pedido revisional parcialmente deferido, tão-somente para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento de pena. (TJ-SP - RVCR:

9015719932005826 SP 9015719-93.2005.8.26.0000, Relator: Sérgio Ribas, Data de Julgamento: 15/09/2011, 3º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação:

16/09/2011)”

“Tráfico - Ingresso em domicílio sem mandado judicial - Apreensão de droga - Crime permanente - Flagrante - Prova lícita. (TJ-SP - RVCR: 00205789620148260000 SP 0020578-96.2014.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6º

Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2015)"

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelos laudos periciais de constatação provisória (fls. 22/27 e 28/33), pelas fotografias da droga (fls. 53/56), pelos laudos de exame químico toxicológico definitivos (fls. 163/165 e 166/168), pelo laudo pericial de degravação de celular (fls. 170/175), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação Everaldo Menezes Santos, policial militar, disse que tinha informações de que o réu encontrava-se com um DelRey. Ele se mudou de Dracena para cidade de Ouro Verde. Avistou o réu no Posto de Gasolina e, realizada a abordagem, ele disse que na casa dele havia drogas para seu consumo pessoal. Na residência do réu foi localizado vinte gramas de "maconha" e dentro da argamassa tinha três tijolos de "maconha". No total foi apreendido quase meio quilo droga e o aparelho celular. Não teve acesso ao aparelho celular. O réu era conhecido nos meios policiais porque já foi apreendido duas vezes por tráfico de drogas. O réu não apresentava estar sob efeito de drogas (cf. mídia).

A testemunha de acusação Paulo Cesar Gonçalves de Oliveira, policial militar, disse que no dia do fato, durante patrulhamento em Ouro Verde, já de conhecimento por denúncias de que o réu, morador recente da cidade de Ouro Verde, praticava o tráfico de drogas. Avistou o réu no Posto de Gasolina com o veículo Del Rey que era objeto das denúncias. Em abordagem, o réu disse que tinha em sua residência uma certa quantidade de "maconha" para seu uso. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. De lá partiram para a residência do réu e, com autorização do réu e de sua esposa Stefany, adentraram a residência e localizaram sobre a geladeira as 20g de maconha que o réu havia informado. Indagado e advertido que acionaria o canil, o réu indicou um local da argamassa no qual havia três tijolos de "maconha" que seria posteriormente destinado ao comércio. O local da argamassa é o fundo da residências do réu, que é fechado, toda cercado de muro. O réu apresentava-se lúcido. Não teve acesso ao celular do réu na data do fato que, inclusive, o celular acabou a bateria. A denúncia que recaía sobre o réu foi trazida pelo sargento Menezes de que um recente morador de Ouro Verde utilizava-se de um veículo Del Rey de cor dourada, mas no documento era de cor bege, e que ele praticava o tráfico de drogas na residência e utilizava o veículo para buscar as drogas e posteriormente entregar as drogas. O réu possui duas condenações por tráfico e uma pelo artigo 171 CP (cf. mídia).

A testemunha de defesa Rafael Leite disse que é patrão do réu. Os policiais mexeram no celular do réu. Foi dirigindo o carro do réu. Não viu quando os policiais adentraram a residência do réu. O réu é usuário de drogas (cf. mídia).

Em seu interrogatório judicial, o réu WAGNER ROBERTO VIEIRA DA SILVA disse que estava no posto de gasolina com seu patrão. Abasteceu trinta reais de combustível. Os policiais o abordaram e indagaram se tinha droga no carro e que iriam dobrar a quantidade de droga que tinha. Indagado, o réu disse que tinha droga na sua casa para fumar. Os policiais apreenderam sua maconha que estava em cima da geladeira. Trabalha desde os quinze anos de idade e nunca precisou vender droga na sua vida. Já teve passagem por tráfico mas a droga era para seu consumo pessoal. Guardou a droga na argamassa porque não pretendia ficar indo na biqueira buscar droga em pequena quantidade. Usava drogas no quintal de sua casa. Tem três filhos que são cuidados por sua mulher e o interrogando. Com relação à conversa localizada em seu celular, justificou que usava droga com o Carlos Henrique. Quem levava a droga para usar com Carlos Henrique era o interrogando. Sempre iaapé. Trabalhava na marmoraria e ganhava R\$ 1.800,00. Pagou a quantia de R\$ 800,00 na droga localizada na argamassa (cf. mídia).

De toda instrução, vislumbro que a negativa do réu não merece crédito, pois divergente do arcabouço probatório produzido, com nítida intenção de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito praticado. O conjunto probatório produzido indica que a substância entorpecente apreendida pertencia ao réu e destinava-se à traficância. Isso porque, várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a

formação de convicção no sentido da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida: (a) a natureza e a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, a saber: 03 (três) porções de maconha pesando 338,33g (trezentos e trinta e oito gramas e trinta e três centigramas) de massa líquida (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 16/17; laudo provisório de fls. 22/27 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 163/165), além de 01 (uma) porção da mesma substância pesando 26,07g (vinte e seis gramas e sete centigramas) de massa líquida (cf. Auto de exibição e apreensão fls. 16/17; laudo provisório de fls. 28/33 e laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 166/168); (b) o laudo pericial de fls. 170/175 realizado no aparelho celular apreendido na posse do réu, constando conversas relacionadas à comercialização de drogas, bem como imagens da substância encontradas na galeria de fotos; (c) a existência de denúncias do envolvimento do réu com a prática do tráfico de drogas, conforme depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo.

Segundo a prova oral, os policiais militares realizavam patrulha quando se depararam com o acusado em um Ford Del Rey no posto de gasolina abastecendo. Por meio de fortes denúncias populares, foram informados que este estaria traficando naquela cidade, motivo que levou a abordagem. Indagado, o réu informou que possuía droga em sua casa. No local, os agentes policiais adentraram na residência, com a devida autorização do réu e de sua esposa, momento em que foi localizada em cima da geladeira 01 (uma) porção de 26,07g de maconha. Na sequência, o acusado indicou um saco de argamassa, localizado no fundo na residência, que possuía em seu interior 03 (três) tijolos prensados de "maconha", com massa líquida de 338,33 gramas. Pois bem, a notícia anônima ou de populares é um instrumento importante de prevenção e repressão de delitos desta natureza. Se a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível que eles encontrassem o réu, no mesmo local, guardando substância entorpecente.

Não se trata de embasar uma condenação apenas em informação anônima, mas sim condenar quem, através dela, restou comprovado que efetivamente cometeu o crime. Ressalte-se que os testemunhos dos Servidores Policiais em Juízo são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, sobretudo o laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 163/165 e 166/168), comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu, vez que dotados de fé pública e idoneidade em suas alegações, mormente por terem corroborado os depoimentos na fase inquisitorial.

Não há razão suficiente a invalidar o depoimento dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de deporem, só porque ostentam essa qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito. A jurisprudência é firme no sentido de que, aliado a outras provas, o depoimento dos policiais é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Nesse sentido:

'PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido'. (Apelação Criminal n. 993.07.105623-5 - Sumaré - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery 06.08.08 - V.U. - Voto n. 13111)

'TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos'. (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.)" (TJSP, Apelação nº 3005426-36.2013.8.26.0082, 10ª Câmara

de Direito Criminal, Rel. Des. FRANCISCO GALVÃO BRUNO, j. 31.03.2016). Ademais, a versão dos policiais militares foi corroborada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 16/17) comprovando a apreensão da droga e do celular que continha imagens da droga, pelos laudos periciais provisórios (fls. 22/27 e 28/33) e laudos definitivos da droga (fls. 163/165 e 166/168) que atestaram positivo para "TETRAHIDROCANNABINOL (THC)".

Outrossim, no laudo pericial de degravação de celular (fls. 170/175) foi possível constatar as trocas de mensagens gravadas no aplicativo "WhatsApp", com um indivíduo de nome de Carlos Henrique, nº +55 18 99653-2989, o réu envia uma foto segurando uma lata de cerveja da marca Brahma e um cigarro de maconha. Em continuidade da conversa, Carlos Henrique diz: "ai ss em", "manda uma pra cá kkk". O réu responde: "tem meio quilo aqui mano", "vou mandar ai", "kkk"[...] (fls. 173). Ainda foram encontradas fotografias na galeria de fotos do aparelho celular do réu expondo as substâncias entorpecentes (fls. 174).

Nesse contexto, a julgar pela expressiva quantidade, natureza e a forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, a saber, 03 (três) porções de maconha pesando 338,33g (trezentos e trinta e oito gramas e trinta e três centigramas) de massa líquida, prensadas e embaladas em plástico branco (cf. fotografia de fls. 53/54), e 01 (uma) porção da mesma substância pesando 26,07g (vinte e seis gramas e sete centigramas) de massa líquida, esfarelada e acondicionada em pote plástico (cf. fotografia de fls. 55/56) (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17), aliada à existência de denúncias de traficância envolvendo o réu e o conteúdo da mensagem localizada no celular do réu, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Ainda, importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, ainda que o réu não tivesse sido flagrado comercializando a substância entorpecente, o simples trazer guardar drogas é suficiente para que se configure o tráfico ilícito de drogas, sendo dispensável a oitiva de eventuais compradores usuários.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes." (RT 584/347).

Portanto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente precisa ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

De outra parte, a circunstância de ser o réu usuário de drogas não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, pois nada impede que as figuras de usuário e traficante recaiam sobre a mesma pessoa.

No mesmo sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de

maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES: "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e suas condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Ade ler. Al. Legislação Criminosa Especial. VI. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197)."

A propósito, convém transcrever que a decisão publicada na RT 546/327, para confecção de um "fininho de maconha" são necessários 0,33g da referida droga, o que indica que a maconha que estava em poder do réu, cujo peso totalizava 364,40 gramas, era suficiente para confecção de mais de 1.100 (um mil e cem) cigarros! Isso deriva do seguinte entendimento: "por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração, a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente" (Legislação Penal Especial, Editora Atlas, 3ª edição, São Paulo, 2000, citando julgado colacionado na RT 546/327).

Com efeito, não prospera a tese de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, motivo pelo qual fica afastada a pretensão de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, aliado às provas que se produziu em Juízo, são suficientemente harmônicos e aptos a ensejar a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, pois demonstrado que, na espécie, o réu infringiu a norma do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, por, ao menos, manter em depósito e guardar consigo substância entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, bem como em vista a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, incompatível com o porte para consumo pessoal, tudo indicando claramente o tráfico. Diante do conjunto probatório não há como se acolher o pleito de desclassificação para o crime do artigo 28 ou artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Deve-se, também, reconhecer que a prova colhida, principalmente em razão da versão apresentada pelos policiais em Juízo é firme o suficiente para se concluir que o celular apreendido em poder do réu era utilizado para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser declarado perdido.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Na primeira fase da dosimetria da pena, há previsão legal expressa permitindo ao juiz, na fixação das penas, considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (artigo 42 da Lei nº 11.343/06). Assim, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (03 (três) porções de maconha pesando 338,33g, e 01 (uma) porção da mesma substância pesando 26,07g), o que evidencia o intenso (e demais graves consequências) tráfico a ser praticado e trouxe maior grau de censurabilidade à conduta do réu, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, exaspero a pena-base em 1/6 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A propósito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A motivação adotada pelo Tribunal a quo para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente. Foram indicados elementos concretos que demonstram serem desfavoráveis as circunstâncias do crime, ressaltada a grande quantidade de entorpecentes apreendida (96 papérolas de cocaína). 2. Em consequência, não se mostra possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, tendo-se presente que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e a pena imposta é de 8 (oito) anos. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 124554 MS 2008/0282818-9, Relator: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, DJ: 22/08/2011, 6ª T, Data de Publicação: DJe 31/08/2011)".

"(...) No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida (no caso, 18 pedras e 4 pedras grandes de crack, 65 papérolas de cocaína, 01 bucha de maconha) e variada a natureza. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso no sentido de que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto". (STJ - HC: 214180 ES 2011/0172672-2, Relator: Ministra Laurita Vaz, DJ 22/10/2013, T5 DJe 05/11/2013)".

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência, pois o réu apresenta condenação com trânsito em julgado no dia 09/03/2018, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º do SISNAD, artigo 311, "caput", e artigo 69, "caput", ambos do Código Penal (Autos nº 0006983-40.2016.8.26.0168 - cf. certidão 58/59), portanto, é reincidente específico, motivo pelo exaspero a reprimenda-base em 1/3 (um terço), totalizando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Nessa fase, convém ressaltar que não é o caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea porque o réu negou o fato, dizendo que a droga encontrada em sua residência destinava-se ao seu consumo pessoal e que não precisa vender drogas.

Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que o presente caso não se subsume as hipóteses de aplicação do privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque tal privilégio foi previsto aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já que o réu é reincidente específico, pois apresenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, no caso presente, o acusado guardava em sua residência expressiva quantidade de substância entorpecente "maconha", tudo a indicar a sua dedicação às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito um modo de vida, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de extrema gravidade. Se essa quantidade de droga entrasse em circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.

A propósito, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a quantidade, a diversidade e a natureza da droga justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Confira-se:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL DE N.º 1444115-3 3ª CCRIMINAL 3. Caso em que a expressiva quantidade de droga encontrada (120kg de maconha) demonstra a dedicação do paciente às atividades criminosas e afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, enfraquecendo a alegação de ocorrência de bis in idem. Precedentes do STF. (...) (STJ, HABEAS CORPUS Nº 308.682 - MS (2014/0293393- 8), rel. Min. Gurgel De Faria, julg. 08/09/2015)."

Assim, torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59 do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente específico, aliado ao fato de que tráfico ilícito de substância entorpecente é conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até mesmo a vida de considerável parcela da população, composta basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, raramente dele conseguem se livrar. Além disso, se constitui em porta aberta para o cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o patrimônio, sabido que não raro usuário destituído de capacidade econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para sustentar o vício. Cuida-se, ademais, de conduta equiparada a crime hediondo. Mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Tudo, enfim, a justificar maior rigor na retribuição.

Considerando o montante de pena aplicado, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Ademais, tais institutos, além de se mostrarem incompatíveis com o regime fechado fixado para cumprimento da pena, não se mostram socialmente recomendáveis e suficientes à repressão do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu WAGNER ROBERTO VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 84/94), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do réu e em se tratando de réu reincidente específico que apresenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral; c) oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do aparelho celular apreendido em poder do réu (cf. autos de exibição e apreensão a fls. 16/17) em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Considerando que o réu informou rendimento mensal de R\$ 1.800,00, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.



Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Dracena, 09 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA